

0007137-61.2020.8.26.0348

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Estelionato

Magistrado: Paulo Antonio Canali Campanella

Comarca: Mauá

Foro: Foro de Mauá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/08/2022

... propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, não procede a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mauá

Foro de Mauá

2ª Vara Criminal

Av. João Ramalho, 111, Mauá - SP - cep 09371-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0007137-61.2020.8.26.0348 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0007137-61.2020.8.26.0348

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Estelionato

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WILSON GEOVANE HENRIQUE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Paulo Antonio Canali Campanella

Vistos.

WILSON GEOVANE HENRIQUE SILVA e MARIA NEIDE FREIRE DE ALENCAR foram denunciados por incursão no caput do art. 171 do Código Penal.

Narra a denúncia que entre o dia 06 de outubro de 2011, por volta das 13h00min, e o dia 21 de outubro de 2011, na Avenida Governador Mário Covas Júnior, 01, loja 75, Mauá, e na Avenida Brigadeiro Faria Lima, 180, São Bernardo do Campo, os acusados, agindo em concurso de agentes e identidade de propósitos com outro indivíduo que se identificou como "Ronaldo", concorreram, de qualquer modo, para que obtivessem, para si ou para outrem, vantagem ilícita totalizando R\$ 2.000,00 (dois mil reais), em prejuízo de Fabiano da Cruz França e Rafael da Silva, induzindo-os e mantendo-os em erro, mediante meio fraudulento.

Os autos foram desmembrados, em razão da proposta de suspensão condicional do processo oferecida e aceita pela ré Maria Neide (autos nº 0001986-

95.2012.8.26.0348).

Recebida a denúncia (fl. 222), o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal para o réu Wilson (fl. 233).

Posteriormente, o réu foi citado (fl. 270) e apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução, a vítima foi devidamente inquirida. Por fim, interrogou-se o réu.

Em memoriais, o Ministério Público requer a procedência da ação penal, enquanto a Defesa suscita, em preliminar, o reconhecimento da decadência, além da nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a absolvição ante a insuficiência de provas ou, ao menos, a fixação da pena no patamar mínimo, sob regime inicial aberto, além da substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos.

É a síntese do necessário.
Fundamento e decido.

As preliminares suscitadas pela Defesa não merecem acolhimento.

Alinho-me aos que entendem não configurar decadência a ausência de representação, quando oferecida a denúncia em data anterior à superveniência da novel disposição legal. As vítimas registraram ocorrência (fls. 03-5), a indicar o desejo de ver o réu processado, sendo inexigível formalidade específica para suas manifestações.

Registre-se, ainda, que a denúncia foi devidamente recebida e produzido os seus efeitos legais, não sendo razoável que a lei nova desconstitua ato jurídico perfeito e acabado. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. LEI N. 13.964/2019. INCLUSÃO DO § 5º DO ART. 171: AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NEGATIVA DE APLICAÇÃO RETROATIVA DA NOVA CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE À CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM RECURSO ESPECIAL. MANIFESTAÇÃO INEQUÍVOCA DA VÍTIMA: REPRESENTAÇÃO QUE INDEPENDE DE FORMALIDADES. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. (STF, Habeas Corpus nº 188.498-SP, rel.^a Min. Cármen Lúcia, Decisão Monocrática, j. 16/07/2020).

AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ESTELIONATO. PRETENDIDA APLICAÇÃO RETROATIVA DA REGRA DO § 5º DO ART. 171 DO CÓDIGO PENAL, ACRESCENTADO PELA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). INVIABILIDADE. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. DOUTRINA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Lei n. 13.964/2019, de 24 de dezembro de 2019, conhecida como "Pacote Anticrime", alterou substancialmente a natureza da ação penal do crime de estelionato (art. 171, § 5º, do Código Penal), sendo, atualmente, processado mediante ação penal pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for: a Administração Pública, direta ou indireta; criança ou adolescente; pessoa com deficiência mental; maior de 70 anos de idade ou incapaz. 2. Observa-se que o novo comando normativo apresenta caráter híbrido, pois, além de incluir a representação do ofendido como condição de procedibilidade para a persecução penal, apresenta potencial extintivo da punibilidade, sendo tal alteração passível de aplicação retroativa por ser mais benéfica ao réu. Contudo, além do silêncio do legislador sobre a aplicação do novo entendimento aos processos em curso, tem-se que seus efeitos não podem atingir o ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia), de modo que a retroatividade da representação no crime de estelionato deve se restringir à fase policial, não alcançando o processo. Do contrário, estar-se-ia conferindo efeito distinto ao estabelecido na nova regra, transformando-se a representação em condição de prosseguibilidade e não procedibilidade. Doutrina:

Manual de Direito Penal: parte especial (arts. 121 ao 361) / Rogério Sanches Cunha – 12. ed. rev., atual. e ampl. – Salvador: Editora JusPODIVM, 2020, p. 413. 3. Ademais, na hipótese, há manifestação da vítima no sentido de ver o acusado processado, não se exigindo para tal efeito, consoante a jurisprudência desta Corte, formalidade para manifestação do ofendido. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, Ag Rg na PET no AREsp nº 1.649.986-SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T, j. 23/06/2020).

APELAÇÃO CRIMINAL – “A Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, inseriu o § 5º no artigo 171 do Código Penal, dispondo que o crime de estelionato, em regra, é de ação penal pública condicionada à representação, exceto se a vítima for a Administração Pública, direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental, maior de 70 (setenta) anos de idade ou incapaz. Cuida-se a novatio legis de norma penal mais benéfica e, por conseguinte, deve retroagir em favor do acusado”. “(...) contudo, verifica-se que a vítima compareceu à Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência (fls.) e prestou declarações acerca dos fatos narrados na denúncia (fls.), o que demonstra, indubitavelmente, a manifestação de vontade, livre e consciente, em ver a acusada ser processada pelo crime de estelionato”. “(...) o registro da ocorrência perante a autoridade policial equivale à representação para fins de instauração da ação penal”. Condição de procedibilidade satisfeita. Recurso improvido. (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0038092-69.2014.8.26.0224, rel. Des. Fernando Torres Garcia, 14ª Câmara Criminal, j. 08/05/2020).

APELAÇÃO – Estelionato – Nova Lei nº 13.964/19 – Ação penal condicionada a representação – Condição de prosseguibilidade já que a necessidade de representação é norma mais benéfica ao réu, devendo, pois, retroagir – Desnecessidade, contudo, de conversão do julgamento em diligência – Intenção de processar o acusado que é inferida do registro das declarações do ofendido, em solo policial e em juízo, e do prejuízo suportado que é suficiente a demonstrar ânimo em ver o réu processado pelo delito em tela (...). Recurso desprovido. (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0002375-48.2017.8.26.0205, rel. Des. Xisto Rangel, 13ª Câmara Criminal, j. 10/08/2020).

Apelação da Defesa – Estelionato – Exigência de representação da vítima, após a reforma legislativa introduzida pela Lei n. 13.964, de 24 de dezembro de 2019 – Prescindibilidade de formalidade da medida – Comportamento da vítima durante do processo criminal a revelar a sua intenção quanto a ver o acusado processado pelo crime então praticado (...) – Recurso provido. (TJ/SP, Apelação Criminal nº 0007247-66.2015.8.26.0047, rel. Des. César Augusto Andrade de Castro, 3ª Câmara Criminal, j. 04/08/2020).

Afasta-se, ainda, o pleito de nulidade da instrução por ofensa ao § 14 do art. 28-A do Código de Processo Penal.

O acordo de não persecução penal não é direito subjetivo do réu, mas ato discricionário do Promotor de Justiça. No mais, diante da recusa do Ministério Público, os autos foram remetidos ao Procurador Geral de Justiça, nos termos do §14 do art. 28-A do Código de Processo Penal, que insistiu na recusa de oferta do referido acordo (fls.290-301).

Ressalta-se que o acordo de não persecução penal não pode ser imposto pelo Judiciário em caso de recusa do Ministério Público. Neste sentido precedentes do e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Acerca do acordo de não persecução penal, trata-se de uma discricionariedade do Ministério Público, eis que o artigo 28-A do Código de Processo Penal dispõe que: 'Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo

de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime (...)''. Ou seja, trata-se de um dispositivo legal não vinculante, não devendo o Poder Judiciário interferir na obrigatoriedade de sua aplicação." (HC 2026314-51.2020.8.26.0000, Rel. Ricardo Sale Júnior, j. 05.04.20). g.n.

"Habeas Corpus. Insurgência quanto à ausência de propositura de acordo de não persecução penal. Tráfico que supostamente viria a ser considerado privilegiado. PGJ que, provocada pelo juízo nos termos do art. 28-A CPP, manteve a recusa do Promotor de Justiça. Posição institucional que deve ser preservada. ORDEM DENEGADA." (TJSP, HC nº 2064200-84.2020.8.26.0000, Rel. Xisto Rangel, j. 05.05.20). g.n.

No mérito, não procede a acusação.

Comprovou-se a materialidade pelos boletins de ocorrência (fls. 03-5 e 09-11), comprovantes de depósito (fls. 12-3), cópia do anúncio de empréstimo (fl. 14), informações de fl. 16 e dados cadastrais dos titulares das contas favorecidas (fl. 50).

A autoria não é certa.

O réu Wilson não foi localizado para ser ouvido em solo policial (fls. 113 e 148). Em juízo, negou a prática delitativa. Sustentou que não participou do crime, apenas emprestou a conta para Maria, sua diarista. Na ocasião, ela disse que receberia dinheiro de um familiar do Piauí. Após receber os valores, ela efetuou o saque e devolveu-lhe o cartão. Acrescentou que não recebeu nada por ter emprestado a conta (mídia digital).

As vítimas Fabiano e Rafael, na fase administrativa, afirmaram que (sic) "no dia em questão tiveram acesso a um anúncio de empréstimo de dinheiro, o qual estava colocado na parede do "Banco do Brasil", da agência Central em seu lado de fora. As vítimas entraram em contato telefônico através do número do telefone indicado ao anúncio, procurando falar com a pessoa que constava neste, tratando-se de "Ronaldo". Quando efetuada a ligação ao número (11) 91565355, (13) 3016-4496, o qual contava no anúncio, de imediato a pessoa que atendera a ligação identificou-se como "Ronaldo", deu as explicações referentes aos empréstimos, inclusive que o dinheiro seria liberado pela "Caixa Econômica Federal" e que ele somente intermediava os empréstimos. As vítimas transmitiram para a pessoa que identificara-se como "Ronaldo", seus dados pessoais, como R.G., CPF, Endereço e mais o número de suas contas bancárias. Isto tudo solicitado por "Ronaldo" para poder iniciar a abertura do empréstimo. Sendo que para cada uma das vítimas, seria creditado em suas contas em data futura os valores de R\$ 10.000,00 (dez mil reais). Ronaldo solicitou de imediato às vítimas que fosse depositado na conta por ele fornecido, tendo como correntista a pessoa de "WILSON GEOVANA H. SILVA", agência 0659 e c/c nº 013 0006736-4, os valores de R\$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), de cada vítima, totalizando os primeiros depósitos R\$ 900,00 (novecentos reais). Ainda em nome de "Wilson", fora depositado o valor de R\$ 200,00 (duzentos reais) sendo R\$ 100,00 (cem reais) de cada vítima. Isto solicitado por "Ronaldo" após os primeiros depósitos. Ronaldo, ainda ligou para as vítimas, dizendo que para a liberação do empréstimo, as vítimas teriam que depositar mais o valor de R\$ 500,00 reais. E após, através ainda de ligação telefônica, solicitou mais um depósito para as vítimas no valor de R\$ 400,00 (quatrocentos reais, os valores sempre eram divididos pelas vítimas. Estes dois últimos depósitos foram feitos em nome de "MARIA NEIDE FREIRE DE ALENÇAR", agência 0346 c/c nº 0000998-0. 023 Depois do último depósito efetuado, as vítimas tentaram efetuar ligação, telefônica para a pessoa que identificara-se como "Ronaldo", mas estes não foram mais atendidos. Tais ligações foram efetuadas, em 24/10/2011. As vítimas tiveram prejuízos financeiros e os depósitos do empréstimo, até o presente não fora efetuado" (fls. 03-4 e 17-8).

Sob o contraditório, Rafael reiterou integralmente o ocorrido. Afirmou que não teve contato com ninguém e somente conversou com uma pessoa, que provavelmente seria "Ronaldo", mas não se recordou com certeza do nome em razão do tempo transcorrido (mídia digital).

O conjunto probatório não é suficiente para respaldar o édito condenatório.

A versão exculpatória do réu, no sentido de que apenas emprestou sua conta bancária para uma antiga diarista, não foi infirmada pelos demais provas produzidas.

A vítima não teve contato com o estelionatário, que se intitulou como "Ronaldo", de forma que não há nos autos elementos capazes de imputar a autoria da fraude à pessoa de Wilson.

Não fosse suficiente, não foram produzidas provas capazes de indicar que o acusado tinha ciência da origem ilícita dos valores depositados em sua conta.

Em casos análogos decidiu o e. Tribunal de Justiça de São Paulo:

Apelação defensiva - Estelionato - Participações dolosas que não vieram explicitadas indene de dúvidas - Empréstimo oneroso de conta corrente para o recebimento de valores, que, por si só, não caracteriza a anuência aos engodos praticados pelo contratante, o que sequer foi narrado na ocasião do acerto - Absolvição que se impõe - Aplicação do princípio "in dubio pro reo" - Exegese do art. 386, VII, do CPP - Recurso provido. (TJSP; Apelação Criminal 0037870-36.2011.8.26.0506; Relator (a): Ivan Sartori; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 08/05/2018; Data de Registro: 14/05/2018). g.n.

[...] RÉU DENIS ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DE TER PRATICADO OS DELITOS DE ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CP, ART. 171 E ART. 288). APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO BUSCANDO A REFORMA DO DECISUM PARA CONDENAR O RÉU DENIS PELO CRIME DE ESTELIONATO. [...] AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DO CORRÉU DENIS NO DELITO DE ESTELIONATO - RACIOCÍNIO PRESUNTIVO A RESPEITO DA AUTORIA E DA CULPABILIDADE QUE NÃO É BASTANTE PARA RECOMENDAR A IMPOSIÇÃO DE PENA - PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA - DOSAGEM DAS PENAS DE WILGNER QUE NÃO MERECE REPAROS - PENA BASE FIXADA COM MOTIVAÇÃO BASTANTE, COM ESTIPULAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS FAVORÁVEL, DEFERIDA A BENESSE DA SUBSTITUIÇÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. "[...] Não obstante, pesem os indícios colhidos, não se tem a cabal demonstração de que DENIS estaria envolvido no crime de estelionato. Anote-se que, embora bastante suspeita a sua conduta de "emprestar" a conta bancária para que fosse efetuado depósito, cujos saques deveriam ser realizados de maneira fracionada, não restou evidenciado que tivesse conhecimento de que a conta seria utilizada pelo corréu para receber dinheiro proveniente de crime, ou mesmo que tivesse participado de qualquer forma do delito de estelionato em referência, até mesmo porque apresentou a mesma versão dos fatos em todas as oportunidades em que foi ouvido. E como já se decidiu nesta e. Corte de Justiça, "não basta um forte grau de probabilismo sobre ter determinada pessoa cometido o crime. Não se compraz, também, para um razoável édito condenatório, com a alta possibilidade de o sujeito incriminado ter sido o autor do fato típico. Tampouco é servível, para recomendar uma pena, um raciocínio presuntivo a respeito da autoria e da culpabilidade criminosas" (Apel. nº 0001787-40.2010.8.26.0414, rel. Sydney de Oliveira Jr., j. em 27.6.2013). [...]" (TJSP; Apelação Criminal 0001139-35.2017.8.26.0537; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de São Bernardo do Campo - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 25/06/2019; Data de Registro: 26/06/2019). g.n.

Nesses termos, não havendo prova segura do dolo de Wilson, a prudência recomenda a absolvição.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o réu WILSON GEOVANE HENRIQUE SILVA, qualificado nos autos, da imputação de ofensa ao caput do artigo 171 do Código Penal, com espeque no inciso VII do art. 386 do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado, expeçam-se as comunicações de praxe e arquivem-se os autos.

Defere-se os benefícios da justiça gratuita (fl. 367).

P.I.C.

Paulo Antonio Canali Campanella - Juiz de Direito
(assinado eletronicamente)

Mauá, 18 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA